



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יהושע שוקי יוסף
באמצעות ב"כ: עו"ד כהן עדי
שד' נים 2 ראשון לציון
טל': 052-3234008 פקס: 03-97413742

התובע:
(הנתבע שכנגד)

נגד

1. אפרים ברהום
2. ליליאן ברהום
3. יוסף ברהום

הנתבעים:
(הנתובעים שכנגד)

באמצעות ב"כ: עו"ד דרדיק אירית
ת"ד 548 כפר סבא
טל': 052-5776571 פקס: 09-7401175

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה להורות על התקנת גדר הפרדה בין תתי החלקות, להסיר חלונות ותריסים שהותקנו שלא כדין ותיקון גגון אשר מוביל מי גשמים אל חצרו של התובע (להלן - "התביעה" או "התביעה הראשית") וכן תביעה שכנגד לקבלת דמי שימוש ראויים בגין הסגת גבול ומתן צו עשה להריסת בנייה לא חוקית (להלן - "התביעה שכנגד").

העובדות וההליכים בקצרה

1. עניינה של התביעה והתביעה שכנגד בבית משותף ברחוב שחל 53 בהוד השרון, הרשום בפנקס הבתים המשותפים כחלקה 179 בגוש 6657 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משתי תתי חלקות שבכל אחת מהן מבנה צמוד קרקע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. בתאריך 31.5.1984 נרשם הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים; בתוך כך אושרו ונרשמו לבית המשותף צו ותקנון מוסכם (להלן - "הצו" ו"התקנון המוסכם").
3. התובע, יהושע שוקי יוסף, רשום כבעל זכות חכירה בתת חלקה 2 בבית המשותף (להלן - "התובע" או "הנתבע שכנגד").
4. הנתבעת 2 ליליאן ברהום, רשומה כבעלת זכות חכירה בתת חלקה 1 בבית המשותף, אפרים ברהום, הוא בעלה של נתבעת 2, הנתבע 3 יוסף ברהום, הוא בנם של הנתבעים 1 ו-2 (להלן - "הנתבעים" או "התובעים שכנגד").
5. בכתב התביעה הראשית עתר התובע לצו עשה להורות לנתבעים להתקין גדר הפרדה בין דירות הצדדים לאחר שהגדר הקודמת הוסרה על ידי הנתבעים בחודש אוקטובר 2020. כמו כן, דרש התובע להורות לנתבעים לסגור פתח בקיר המשותף שפרצו לטובת התקנת חלון הצופה אל דירת התובע וכן לתקן את גגון דירתם אשר מוביל מי גשמים אל חצר התובע (להלן - "כתב התביעה").
6. בכתב הגנה בתביעה הראשית טענו הנתבעים כי יש לדחות את התביעה, שכן בשנת 2019 פנו הצדדים בהסכמה למודד חוסאם מסארוה (להלן - "המודד") כדי לקבל תכנית מדידה בין שתי תתי החלקות כדי שיוכלו לסמן את קווי הגבול ולהתקין גדר חדשה. בתאריך 29.4.2019 הגיש המודד תכנית מדידה שעליה סומן קו הגבול בין שתי תתי החלקות. התובע לא הסכים עם תכנית החלוקה שכן מבנים שהציב בשטח החצר וכן בורות ספיגה שחפר מצויים על פי תכנית החלוקה בשטחם של הנתבעים. בחודש יוני 2020 ביקש התובע מהמודד הבהרה לעניין קו הגבול שיעבור בין תתי החלקות והנתבעים הצטרפו לבקשה זו כדי לגשר על המחלוקת שנוצרה. בתאריך 29.6.2020 התקבלה תשובת המודד כי לא ראה מקום לשנות את מפת המדידה כפי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהוגשה בתאריך 29.4.2019. לעניין הגגון והחלון שהותקן שלא כדין
הנתבעים דוחים טענות אלו (להלן - "**כתב ההגנה**").

7. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה, הוגשה גם תביעה שכנגד (6/513/2021) שבה
עתרו הנתבעים (כתובעים שכנגד) לקבלת פסק דין הצהרתי לתכנית החלוקה
של המודד לקו הגבול כפי ששורטט בתכנית וכן מתן צו הריסה לקרוואנים,
למבנים, ליסודות הלא חוקיים אותם הציב התובע ולבורות הספיגה שחפר
בשטחם של הנתבעים. כמו כן עתרו הנתבעים לחייב את התובע בדמי שימוש
ראויים בגין השגת גבול שאותה עשה התובע בשטחי הנתבעים (להלן - "**כתב
התביעה שכנגד**").

8. בכתב הגנה לתביעה שכנגד נטען על ידי התובע כי טענות הנתבעים בגין פלישה
מעולם לא הועלתה לפני שהתובע רכש את הנכס בדיוק במצבו עם גדר
החלוקה כפי שהוצגה בפניו ערב הסכם הרכישה. לפיכך, יש למחוק את
התביעה בשל התיישנותה. עוד טען התובע כי מאז רכש את זכויות החכירה
לא ביצע כל שינוי בקו הגבול בין דירות הצדדים וכי הגדר שנהרסה על ידי
הנתבעים הייתה מותקנת מקדמת דנא ונהרסה על ידי הנתבעים שלא כדין,
תוך עשיית דין עצמי ושינוי סטטוס קוו שהיה קיים ערב רכישת זכויות
החכירה על ידי הנתבע שכנגד (להלן - "**כתב הגנה לתביעה שכנגד**").

9. לאחר שהתקיימו שני קדמי משפט בנוכחות הצדדים, נקבעו ההליכים
שבכותרת להוכחות. יצוין כי הצדדים הגיעו להסכמות בקשר לסעד שביקש
התובע ביחס לגגון, ומשכך נושא זה אינו במחלוקת. (עמ' 6 ש' 40-41
פרוטוקול דיון מקדמי מתאריך 29.12.2021, עמ' 10 ש' 39 פרוטוקול דיון
מקדמי שני מתאריך 13.6.2022)

10. בתאריך 25.12.2022, התקיים דיון הוכחות שבמסגרתו העידו העדים
הבאים: מטעם התובע העידו אחיו, מר יוסף כרמי, והתובע עצמו, מר יהושע
שוקי יוסף. מטעם הנתבעים העידו: המודד - חוסאם מסארוה, הנתבע 3, מר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יוסף ברהום, הנתבע 1 מר אפרים ברהום, הנתבעת 2, גברת ליליאן ברהום
(להלן - "פרוטוקול דיון ההוכחות").

תמצית טענות התובע (הנתבע שכנגד) בסיכומיו

11. קיימת היעדר יריבות משפטית של התובעים שכנגד 1 ו - 3, לדרוש סילוק יד במקרקעין, מאחר שאינם בעלי זכויות בבית המשותף.

12. קיים שיהוי ניכר בהגשת התביעה לסילוק יד והתיישנות. הגדר הייתה בנויה בקו הגבול בין שתי החלקות מזה עשרות שנים. אפשר לראות זאת בעדותו של יוסף ברהום, עמ' 11 לפרוטוקול שורות 5-8 ובעדותה של ליליאן ברהום עמ' 14 שורות 29-30.

13. כבוד המפקח נעדר סמכות לדון בתביעתם של התובעים שכנגד לסילוק מבנים. הסמכות להורות על הריסת מבנים או הוצאת צו הריסה מוקנית לוועדה המקומית וככל וסבורים התובעים שכנגד כי הוועדה לא עשתה את עבודתה, רשאים הם לפנות בעתירה מנהלית לבית המשפט המוסמך.

14. מדובר בבתיים שנבנו אי שם בשנות ה - 50, גם של התובע וגם של הנתבעים, הבית של הנתבעים הורחב באמצעות תוספות בנייה בשנות ה - 70 וה - 80, מידע זה נתמך בצו רישום הבית המשותף שנרשם ב - 1984 עם השטחים החדשים.

15. במרוצת השנים מעבר לתוספות הבנייה, הונחו מבנים במקרקעין, כל אחד בחלק שלו - קראוונים, ומבנים ארעיים. נשתלו עצים וצמחייה. כל צד עשה זאת במשך עשרות שנים, ובמקרה של התובע גם הבעלים שממנו רכש את הדירה.

16. הרכוש המשותף המוגדר היום בתקנון, לא נהגו בו כרכוש משותף, עשו בו שימוש מלא כבהצמדה ולאף אחד מהצדדים לאורך השנים לא הייתה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התנגדות עד כה. הסיבה היחידה שבגללה התעוררה שאלת הגבולות היא בשל הצורך של הנתבעים להכשיר מבנים חורגים בשטחם, דבר שהביאם לשכור מודד כדי לערוך מפה טופוגרפית.

17. המודד כמומחה מחויב להציג באותה מפה טופוגרפית את גבולות החלקה המדויקים, לרבות הפקעות. הנתבעים גילו כי יש להם הפקעה בחלקה וביקשו לשנות את הגבולות שמא לא ייפגעו מאותה ההפקעה.

18. אין חולק כי הנתבעים משתמשים בחלק שהופקע על ידי העירייה, כפי שהעיד המודד והנתבעים בעצמם אך הם רוצים להשתמש בשטח נוסף השייך לתובע. לשיטתם החלוקה צריכה להתבצע רק בגבול שבין התובע לנתבעים ולא בגבול הטבעי של החלקות.

19. במרוצת השנים הגישו הנתבעים בקשות להיתר, במסגרתן הוגשה תכנית המאשרת את המצב הקיים. לא היה לנתבעים כל טענה במרוצת השנים בדבר השטח. הרי אם הייתה כזו טענה הרי היו מעלים אותה עוד בשנות ה - 70 וה - 80, התנהגות הצדדים לאורך השנים, מלמדת אף מכללא על הסכמות הצדדים לרישיון שימוש ייחודי בחצרות הבית. מהראיות שבתיק ומעדויות אנו למדים כי הנתבעים סיפחו לעצמם חלק ספציפי בחצר המשותפת.

20. סעיף 62 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "חוק המקרקעין") קובע כי לשם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה פלונית, נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות. דין דומה חל בפסיקה, כאשר עושים שימוש ייחודי ברכוש משותף אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין.

21. ברישום הבית המשותף המבנים עצמם יוחדו, אך שטח הקרקע לא הוצמד לאף אחת מהדירות. ידוע לפי הסכמי החכירה של שני הצדדים, כי לכל צד מגיע 654.5 מ"ר בשטח, אך כל שאר השטח נשאר כרכוש משותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. עוד נקבע בפסיקה, כי אותה הסכמה לחלוקת השטחים יכולה להיות גם בעל-פה ואין חובה שתינתן בכתב. יש לכבד את התנהגות והסכמת הצדדים לאורך השנים בדבר החלוקה. וזאת בייחוד מקום שבו השינוי המבוקש לא יגרום נזק.

23. בפס"ד רוקר נ' סולומון ישנה רשימה של שיקולים ארוכים שעל בית המשפט לשקול כאשר הוא נאלץ לפגוע בקניינו של הזולת. מעדותו של התובע אנו למדים כי העלות שתיגרם לו לצורך הזזת בורות הספיגה, הצנרת והמבנה היושב על הגבול, היא עלות שאינו יכול לשאת בה. מדובר בכמה מטרים בודדים בלבד כאשר התובעים שכנגד לא הצביעו על נזק כלשהו שעלול להיגרם להם מהשארית המצב הקיים.

24. יש לקבל את התביעה תוך דחיית התביעה שכנגד, ולהורות על בניית הגדר מחדש על ידי הנתבעים, שהודו בצורה חד משמעית שהם הרסו אותה, וזאת בהתאם לקו הגבול שהיה עשרות שנים וזאת כדי לצמצם את הפגיעה שעשויה להיגרם לתובע.

25. יש להורות על סגירת החלונות וביטול אותה הפרעה ממשית הנגרמת לתובע בביתו הפרטי, בקניינו. כמובן להימנע מלגרום כל נזק לרכוש התובע או להתנגד לבנייה בחלקו. גם התובע לא יתנגד לחתום על כל תכנית.

26. יש לפסוק הוצאותיו של התובע על שנאלץ להגיע כדי לשמר מצב קיים וגם בגין ההגנה בתביעה שכנגד וכן לפסוק שכ"ט עו"ד לפי התקנות.

תמצית טענות הנתבעים (התובעים שכנגד) בסיכומיהם

27. אין כל שינוי או התיישנות. חוסר השוויון בחלוקה הקודמת התגלה רק לאחרונה בשנת 2020, לאף אחד מהצדדים לא היה מושג לגביו, ומיד בוצעו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פעולות פיזיות להפסקת חוסר השוויון. כמו כן, בטענות של פלישה והשגת גבול אין התיישנות, ידוע שמדובר בפעולות מתחדשות.

28. אין מדובר בתביעה לשינוי גבולות, גבולות החלקה ברורות, מדובר על הסכמות לגבי שימוש ייחודי ובלעדי בשטח שהוא משותף.

29. מספיקה הסכמה בעל פה כדי לעשות חלוקה זו של שימוש ייחודי ובלעדי, אך על פי דין אפשר לחזור מהסכמה כזו בכל עת.

30. התברר כי התובע עושה שימוש ייחודי ובלעדי באופן לא שוויוני בשטח שיותר גדול מהשטח של הנתבעים. רשות לעשות שימוש ייחודי ובלעדי באופן שהיה נהוג, תתבסס על הנחה של שוויוניות.

31. הנתבעת 2 העידה כי אם תרצה למכור את הנכס או לעשות שימוש כזה או אחר בנכס, צריך שהשוויוניות תבוא לידי ביטוי.

32. התובע טען בסיכומיו כי ייגרמו לו נזקים משמעותיים שהוא יצטרך לעשות עבודות בגובה אלפי שקלים, אך אלו טענות שנטענו בעלמא. בקלות יכול התובע להוכיח שייגרמו לו נזקים, התובע היה יכול להביא הצעת מחיר מבעל מקצוע, לשאול את המומחה. אך התובע למעט עדות אחיו שכולה הייתה מן השמועה וחסרת משמעות עם אפס משקל. התובע לא הביא לתיק זה שום דבר.

33. לעניין התריס והגגון התובע לא הביא כל ראיה שנגרם לו נזק כלשהו, שום אסמכתא חיונית כזו או אחרת שהתריס לא היה אמור להיות. הרי אין חולק כי המצב היה כך כשרכש התובע את דירתו. התובע אף ויתר על העדת הבעלים הקודם.

34. לעניין הגדר, מדובר בהריסה בהסכמה, שבוצעה לאור מדידה שבוצעה בהסכמה, במטרה להציב גדר חדשה ותקנית וקו גבול שייקבע על ידי איש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקצוע בכלל ולא על ידי הנתבעים. זו הייתה גדר ישנה וחלודה שלתובע לא הייתה מעורבות בהצבת הגדר ונסיבותיה.

35. הסעד העיקרי שעתרו לו הנתבעים הוא הצבת גדר בגבול הצהוב שמדד המודד. אין מחלוקת כי הגבול הצהוב נותן שוויון בין הצדדים.

36. השטח שבו משתמשים הנתבעים וכפי שהסביר המודד אינו הפקעה אלא חלקת דרך כפי שהייתה במקור מחוץ לחלקה. התובע עצמו אמר שכך נהוג בשכונה וכך פעלו גורמים נוספים והעירייה פעלה לפנות את הפלישה בעבר, העניין בטיפול ובסוף השטח יוחזר לעירייה.

37. התובע טוען כי מגיע לו יותר בשטח כי הנתבעים עושים שימוש נוסף בשטח שמחוץ לחלקה לא טענה שיכולה לעמוד לתובע. התובע לא הביא שום מומחה נוסף, שום מדידה אחרת, שום הצעה אלטרנטיבית. בפנינו רק המדידה של מר חוסאם.

38. אין מחלוקת שהצדדים רוצים את ההפרדה הזו, לא נותרה לכבוד המפקח ברירה אלא לקבוע את הגבול ומיקום הגדר.

39. במקרה שכבוד המפקח לא יוכל לקבוע את קו הגבול ומיקום הגדר, המשמעות היא שכל השטח הופך לשטח משותף קלאסי של שימוש סביר. תוך פינוי כל הבנוי בניגוד לצו רישום הבית המשותף לשני הצדדים.

דיון והכרעה

40. אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר שעיינתי בכל המסמכים המונחים בפני, התרשמתי באופן בלתי אמצעי מהעדים שהעידו ושקלתי את טענות הצדדים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החלטתי לדחות את התביעה בהליך הראשי ולקבל באופן חלקי את התביעה שכנגד,
להלן יובאו נימוקיי.

למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעות שעילתן סילוק יד

ודמי שימוש ראויים

41. שאלת הסמכות העניינית היא שאלה הדורשת תשובה ברורה וחדה, וקיומה של אי-בהירות ביחס לחלוקת הסמכויות הענייניות בין הערכאות הדיוניות השונות עלול לפגוע בוודאות המשפטית של בעלי דין ולגרום לבזבוז משאבים של הצדדים ושל המערכת המשפטית כולה [רע"א 6500/19 גבריאלי נ' אשד, בפסקה 10 (7.5.2020); רע"א 7513/15 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ נ' פלונית, פסקה כ"א (21.3.2016)].

42. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות".

43. בהתאם להוראת סעיף זה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם [ראו רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20, (נבו 17.03.2016)].

44. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין, בין היתר, הסמכות לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לרכוש המשותף בבית המשותף; סמכות המקבילה לסמכות בית משפט מוסמך. כך בענייננו, עת בכתב התביעה שכנגד עתרו הנתבעים להורות לתובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לסלק ידו משטח החלקה שלהם, משפלש אל השטח ותופס בו חזקה ייחודית שלא כדין, התקיים התנאי הראשון.

45. בהתייחס לזהות הצדדים, קובע סעיף 72 לחוק המקרקעין, כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בסכסוך שבין בעלי דירות בבית משותף, לרבות מחזיק הדירה מטעם בעל הדירה, מחכיר לדורות, מחכיר משנה לדורות ומתחזק (כהגדרתו בסעיף 71 (ב) לחוק המקרקעין). די באמור כדי לקבוע כי מתקיימים התנאים במצטבר מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין הסמכות לדון בתביעה דנן.

46. סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, מסדיר את דוקטרינת "סמכות נגררת" כפי שהיא מקבלת את ביטוייה במשפט הישראלי וקובע כי אם הובא עניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר.

47. כשם שלבית משפט השלום סמכות שבגררא לדון במסגרת תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין גם במחלוקת לעניין הבעלות בה, כך רשאי המפקח לדון בגררא בשאלה שהכרעתה נדרשת לבירור העניין שלפניו (ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסן, בפסקה 23 (04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)).

48. כך גם לגבי הסעד של דמי שימוש ראויים. בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 3/98 חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני (נבו, 28.2.1999) נפסק כי המפקח על רישום מקרקעין מוסמך על פי סעיף 72(ב) לחוק (אותו סעיף המקנה לו סמכות מקבילה לפסוק בעילת הסגת גבול), לפסוק גם פיצויים בגין הסגת גבול.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

49. סמכות המפקח על רישום מקרקעין לפסוק דמי שימוש ראויים בתובענה שעילתה הסגת גבול היא משום שיקולי יעילות הדיון ומדיניות שיפוטית. שכן, אין זה ראוי שאגב דיון בתיק בסוגיית סילוק יד, לא ידון הטריבוטל הדן ממילא בתיק, גם בסוגיית דמי השימוש הראויים הנובעים מהסגת הגבול, לרבות פיצוי בגין נזק ממון הנובע מעילת הסגת הגבול (285/10 **נציגות הבית המשותף רחוב סוקולוב 66 רמת השרון נ' שלמה צפריר** (נבו 18.01.2011); 398/15 **דגש. חניונים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף בשד' המגינים 53, חיפה**, בפסקאות 78-80 (נבו 26.08.2020); 104/19 **א.ג.ת.ד. בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברחוב הסיבים 48 וברחוב הנשיא 73-75**, בפסקאות 15-12 (נבו 02.01.2020).

50. יודגש כי עילת הסגת גבול ועילת דמי שימוש ראויים הן שתי עילות תביעה נפרדות. עילת דמי השימוש הראויים מקורה בדיני עשיית עושר ולא במשפט. משכך גם נפסק שאין צורך לבקש היתר לפיצול סעדים כאשר מוגשת תביעה נפרדת של דמי שימוש ראויים, בנפרד מסילוק היד (רע"א 1156/02 **עבד אל סלאם חיר נ' עבד אל סלאם חיר** (נבו, 11.5.2003).

51. כפי שכתבתי בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 634/19 **חבאני גדעון נ' קומימי בנימין**, בפסקה 36 (נבו 13.12.2021) (להלן "**עניין חבאני**"), אין המפקח רשאי לדון בדמי שימוש ראויים כעילה עצמאית ויחידה כאשר היא אינה כרוכה עם עילת הסגת הגבול וסילוק יד. בפעמים שבהן נקבע כי המפקח מוסמך לפסוק דמי שימוש, הדבר היה רק כאשר נושא דמי השימוש נדון יחד ובמשולב, וכפועל יוצא מעילת סילוק היד. במקרה כזה קיימת הצדקה כי הטריבוטל אשר ממילא דן בתיק, יפסוק גם בסוגיית דמי השימוש הראויים ולא יטריח ערכאה נוספת לדון בסוגיה שנגזרת מאותה מערכת עובדתית [ראו לעניין זה פסק דינה של כב' המפקחת אסתי שחל בעניין (המפקח על המקרקעין נתניה) 182/17 **נציגות הבית המשותף ברח' אריק לביא 3, נתניה נ' חברת קרן פז לבניין בע"מ**, בפסקה 13 (נבו 27.05.2020)]. אך בשעה שהעילה היחידה שנותרה לדיון כעילה עצמאית, עניינה דמי שימוש ראויים שמקורה בדיני עשיית העושר, אין למפקח על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רישום מקרקעין, הסמכות העניינית לדון בה [(המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 294/11 **נציגות הבית המשותף רחוב עמנואל הרומי 13 תל אביב נ' אוזן** (נבו 01.08.2011)].

52. שאלת סילוק היד שבמחלוקת, דורשת דיון גם במחלוקת הקניינית הקשורה לבעלות הצדדים. אולם בכל הקשור לבעלות והנובע ממנה, אדון אגב גררא בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי בסילוק יד, אדרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת שטח זכויותיהם הקנייניות [ראו והשוו ע"א 10112/03 **גיטה פת נ' דן קטלן-אסן**, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 **ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני**, לח(4) 487 (1984)] והיא אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 514/20 ע.י.ר. **קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון**, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

דין טענת ההתיישנות שהעלה התובע להידחות

53. סעיף 5 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 (להלן - "**חוק ההתיישנות**"), קובע כי תביעה שלא הוגשה עליה תובענה ועניינה מקרקעין מוסדרים מתיישנת בחלוף 25 שנה, וסעיף 6 לחוק ההתיישנות קובע שמניין הימים מתחיל ביום שבו נולדה עילת התובענה. אך כידוע, במקרה של התנגשות בין דין כללי לבין דין מיוחד, האחרון גובר [דנ"א 1595/06 **עזבון המנוח אדוארד ארידור ז"ל נ' עירית פתח-תקווה**, בפסקה 28 (21.3.2013); ע"א 7957/13 **מדרך עוז בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב**, בפסקה 73 (נבו 1.11.2018)].

54. הלכה פסוקה היא שהסגת גבול במקרקעין היא עוולה מתמשכת, במובן זה שעילה לסילוק יד בגינה, מתחדשת מיום ליום, ואינה מתיישנת [ע"א 3137/15 **עירית חיפה נ' קהילת ציון אמריקאית**, פסקה 11 (נבו 21.5.2018); ע"א 1206/16 **חברת יהלומי סמואל - רוזנבאום** (1992) **בע"מ נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה**, פסקה 38 (נבו עמוד 12)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9.10.2018; ע"א 1551/19 פעמי תש"ז, מושב עובדים להתיישבות חקלאית
שיתופית בע"מ נ' גובר, פסקה 12 (נבו 15.1.2020).

55. ובמיושם לענייננו - המקרקעין מושא התביעה, הם מקרקעין מוסדרים, עילת
התביעה שכנגד התהוותה בשנת 2019 לאחר שהוזמן מודד מוסמך לביצוע
מפת מדידה לשטח, ומשכך טענת ההתיישנות שהעלה התובע נדחת.

**דין טענת השיהוי להידחות - התובע לא הוכיח כי עמד בתנאים להוכחת טענת
השיהוי**

56. דוקטרינת השיהוי במשפט האזרחי מוגבלת למקרים חריגים ונדירים, ומטילה היא
נטל כבד על הטוען לה וכי חלוף הזמן אינו נתון בלעדי ואינו נתון בעל חשיבות
עצמאית בעת בחינת השיהוי. בפסיקה נקבעו פרמטרים נוספים, מלבד חלוף הזמן,
השלובים זה בזה אותם נדרש להוכיח לשם קבלת טענת שיהוי, ואלו הם: יצירת מצג
בדבר ויתור על זכויות התביעה ושינוי לרעה במצבו של הנתבע עקב השיהוי בהגשת
התביעה. תנאי נוסף שהוזכר בהקשר זה הוא התנהלות בחוסר תום לב מצד
המשתתף בהגשת התביעה. ומכל מקום, גם כאשר תנאים אלו מתקיימים, עדיין
לערכאה הדיונית שיקול דעת להכריע בדבר המשמעות שראוי להעניק לטענת
השיהוי במקרה הספציפי שלפניה. [ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה
הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים, פ"ד נו 433
(5) בעמ' 445 – 446 (2003); ע"א 5262/08 מילגד בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר
פס"כ"א (נבו 29.7.2010)]. עוד נקבע כי כשמדובר בתביעה לגבי זכות קניינית, יירתע
בית המשפט מחסימתה בטענת שהוי, אף אם התקיימו התנאים דלעיל [ע"א
9839/17 הביטאט בע"מ נ' CAFOM (נבו, 17.12.18)].

57. ובמיושם לענייננו - התובע לא הוכיח כי הנתבעים ויתרו או מחלו על זכותם
הקניינית בשטח שבמחלוקת. ויתור או מחילה על זכות כזו, צריכים להיעשות
על סמך מצג ברור ומפורש, שכאמור לא הוצג לי, אלא להיפך - הנתבעים
הזמינו עם התובע מודד שיערוך מפת מדידה לצורך חלוקת השטח בצורה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברורה ושוויונית בהתאם לגודל השטח הרשום בהסכמי המכר. בנוסף, לא הוכח על ידי התובע כי בשל השיהוי הנטען, שינה הוא את מצבו לרעה, בהסתמכו על מצג הנתבעים. התובע, רכש את זכויותיו בשנת 2016 (הסכם המכר צורף כנספח 1 לתיק מוצגי התובע), ונכנס לדירתו בשנת 2017 (עמ' 6 ש' 4-6 לפרוטוקול דיון ההוכחות) ולא הוכח כי שינה את מצבו לרעה בין מועד רכישת הדירה לבין המועד שבו הוזמן על ידי הצדדים המודד בשנת 2019.

טענת התובע בעניין פתיחת פתח בקיר והתקנת תריסים על ידי הנתבעים -

נדחית

58. לטענת התובע, הנתבעים פתחו פתח בקיר הפונה אל ביתו והתקינו תריסים, דבר הפוגע בפרטיותו וחורג מהיתר הבניה.

59. בעדותו העיד התובע כך (עמ' 6 ש' 26-33 לפרוטוקול דיון ההוכחות):
ש: ספר לנו מה מפריע לך בחלונות להם אתה טוען?
ת: מדובר בתריסים שהם לא מוכנים לסגור למרות בקשתי. מפנה לתמונה בעמ' 39 לתיק המוצגים.
מציג התמונה בצבע. זה הצד של ברהום, הצד השני שלי. הגדר השחורה היתה מהתחלה עד הסוף.
אני מסביר לגבי עמ' 39 לתיק המוצגים, תמונה של תריסים. זה צריך להיות קיר אפס. כמו שהעיד המודד מדובר בקיר הפרדה, זה צריך להיות קיר חלק, קיר אפס. וכמו שרשום ברישומי העירייה בתכנית שהגישו בשנת 1972 ו-1978, כשהרחיבו את הבית, ולפי התכניות שהוגשו להרחבת הבית אין שם חלונות, צריך להיות שם קיר בלוקים סגור, קיר אפס. זה תכניות שהם הגישו. לא הגשתי את התכניות בתיק המוצגים."
יש לי ילדה בת 11, אנו לא רוצים לשבת בבית ופתאום מישהו קופץ מהתריסים מסיבותיו שלו. היו שם תריסים כשקניתי את הבית, הוא אמר לי שהוא סוגר אותם, הוא יכול להעיד. כביכול הוא היה שומר להם על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית, הבית היה מושכר אז הם אישרו לו פחות או יותר, לא בכתב. טענה פה גב' ליליאן ורשום בפרוטוקול שיש לה מסמך חתום שהם יכולים לפתוח שם תריסים. אני רוצה שיוצג לביהמ"ש המסמך שהם טוענים שקיים. בכל מקרה מדובר בקיר אפס ולא ניתן לפתוח שם חלונות או תריסים".

60. יצוין כבר עתה כי התובע טוען שהחלונות הותקנו בניגוד להיתר אך לא צירף את ההיתרים שניתנו בשנים 1972 ו- 1978 כאסמכתאות לטענה שהעלה. כך שהתובע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח טענה זו.

61. לכך יש להוסיף כי התובע אישר כי כאשר רכש את הנכס התריסים היו כבר מותקנים אך הוא ביקש מהנתבעים להסיר אותם (עמ' 6 ש' 34-35 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

62. אף אחיו של התובע, מר יוסף כרמי, נשאל האם התריסים היו קיימים במועד רכישת הנכס (עמ' 5 ש' 15-16 לפרוטוקול דיון ההוכחות).
ש: אך אתה כן יכול לדעת שבמועד רכישת הנכס ע"י אח שלך התריסים היו קיימים.
ת: כנראה שכן. זה לא הופך את זה לחוקי.

63. אף מתצהירו של מר חיים קראוויני אפשר ללמוד כי התריסים הותקנו בתקופתו עוד לפני שהתובע רכש את הזכויות בנכס (נספח 4 בתיק המוצגים) בסעיף 6 נכתב **"עוד אני מאשר כי התריסים שפתחו משפחת ברהום שפונים לכיוון הבית של שוקי יוסף, נפתחו ללא אישורנו..."**

64. יצוין כי ער אני שתצהירו של מר חיים קרוואני נמשך מהתיק, כעולה מהחלטתי (עמ' 9 לפרוטוקול 15.12.2022), בשים לב לכך שלבית המשפט מוקנה שיקול דעת בקשר למשקלו של תצהיר שהעד שהגישו לא התייצב לחקירה נגדית (ראו והשוו ת"א (מחוזי י-ם) 2025-08 **טל בניה והשקעות קרני שומרון נ' פאיז מחמד זאיד רג'בי**, בפסקה 30 (נבו 13.09.2012); ע"מ (מחוזי מרכז) 24557-02-15 **יהודה תלמי נ' פקיד שומה כפר סבא**, בפסקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

42 (נבו 21.01.2018), מצאתי כי יש מקום לייחס לתצהיר זה משקל ראייתי נמוך.

65. ומעל הכול, כפי שכבר כתבתי לא פעם [ראו למשל המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא, בפסקאות 40-42 (נבו 14.03.2022)], המפקח על רישום מקרקעין אינו דן בטענות תכנוניות. המפקח על רישום מקרקעין אמון על הפן הקנייני ואינו דן בתביעות בפן התכנוני, ולכן ככלל, טענה הקשורה להיתרים, אמורה להתברר על ידי מוסדות התכנון ולא על ידי המפקח [עש"א (מחוזי חיפה) 38634-01-20 חנה שטינברג נ' יוגב צבי, בפסקה 58 (נבו 06.07.2020)]. לפיכך, טענותיו של התובע בקשר לפן התכנוני נדחות. אין באמור כדי לגרוע מהזכות העומדת לתובע לפנות לערכאה המתאימה לכך, לרבות למוסדות התכנון, בלי שיש בכך כדי להביע עמדה כלשהי באשר לסיכוייה של פנייה זו.

מסמכי הבית המשותף מעידים כי הייתה כוונה לחלוקה שיוויונית בין שתי

תתי החלקות בבית המשותף

66. הכלל הוא שרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהיה ראיה חותכת לתכנון (סעיף 125(א) לחוק המקרקעין), ועל המבקש לסתור חזקה זו ולהוכיח טעות ברישום, מוטל נטל כבד ומשמעותי [ראו ע"א 1445/11 אברהם מרטינו נ' איתן רילוב (נבו 25.11.2012)]. תכליתו של סעיף 125(א) לחוק המקרקעין היא הבטחת פומביות, אמינות, ודאות וסופיות הרישום במרשם, בכל הנוגע לזכויות הטעונות רישום במקרקעין מוסדרים [ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49, 60(2003)]. נוכח התכלית והצורך להבטיח את יציבותן של זכויות רשומות במקרקעין מוסדרים, לא בנקל ייעתר בית המשפט לתביעה שמטרתה תיקון הרישום, והפסיקה מורה כי נטל ההוכחה על הטוען לתיקון הרישום, הוא כבד [ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (נבו 21.2.07)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

67. עוד מושכלות יסוד הן כי על המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את הדין על פי המצב הרישומי הקיים [ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אוננו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984)]. וכן, כשיש סתירה בין התשריט לבין המלל המופיע בתקנון, או לבין המלל המופיע בטבלת השטחים, יש להעדיף את התשריט [ע"א 3213/97 יחזקאל נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, נג(4) 625 (1999); ת"א (מחוזי י-ם) 3648-09 א.ר.ט. שירותי אחסנה בע"מ נ' מגדלי עסקים (אחזקות) בע"מ, בפסקה 12 (נבו 16.02.2012); ת"א (שלום ק"ג) 5760-03-17 פנינה שטרן נ' אברהם דגורקר, בפסקה 23 (נבו 15.07.2018)].

68. עוד יש להוסיף כי הצמדה כמשמעותה בחוק המקרקעין היא גריעה של חלק מסוים מחלקי הרכוש המשותף ושיוכו לדירה פלונית; עם ההצמדה, חדל אותו חלק מלהיות רכוש משותף, והופך להיות נכס פרטי של בעל הדירה שאליו הוצמד. משמעות הדברים היא שלא חלים על אותו חלק שהוצמד ההוראות הנוגעות לרכוש המשותף ו"דינו לכל דבר כדין הדירה שאליו הוצמד" [סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין; א' אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי – בתים משותפים, עמ' 113]. המשמעות הנגזרת מהצמדה של חלק מסוים לדירה מסוימת היא שבעלי הדירות מאבדים את זכותם הקניינית באותו חלק, ומשכך, נדרשת הסכמתם של כל בעלי הדירות בבית המשותף, "ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות" (סעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין).

69. הצמדה של חלק מהרכוש המשותף לדירה מסוימת טעונה רישום בתקנון המוסכם, כפי שקובע סעיף 55(א) לחוק המקרקעין: "בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית..."

70. דרך נוספת להקניית זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, אפשרית על ידי הסכם בין כל בעלי הדירות לחלוקת הרכוש המשותף, באופן שבו כל דייר מקבל זכות לשימוש ייחודי בחלק מסוים ברכוש המשותף, ובתמורה הוא מוותר על זכותו להשתמש בחלקים אחרים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

71. **ובמיושם לענייננו** - אין מחלוקת שבבית המשותף שלפניי, לדירות לא הוצמדו חלקים מהרכוש המשותף, ולכל אחת משתי הדירות יש חלק בלתי מסוים (1/2) ברכוש המשותף, המתפשט בכל חלק וחלק ברכוש המשותף (סעיף 55א) לחוק המקרקעין). אף במסגרת הסכם המכר שעליו חתם התובע בתאריך 18.8.2016 (הסכם המכר צורף כנספח 1 לתיק מוצגי התובע), במסגרת ה"והואיל הראשון", נכתב מפורשות כי הרכוש המשותף הוא זה "הרשום בלשכת רישום מקרקעין ב-פתח תקווה... נסח טאבו מצ"ב כנספח א' להסכם זה".

72. ואלו הנתונים הרלבנטיים מתוך צו רישום הבית המשותף שנרשם בתאריך 31.5.1984:

המפקח על רישום המקרקעין

לשכת רישום מקרקעין....	גוש 6657
שטרות מספר.....	חלקה 179
תיק לשכה.....	שטח חלקה 1309 מ"ר
ב.מ.....	כתובת שחל 53 הוד השרון

לאחר שהבעלים הרשומים של המקרקעין הידועים בחלקה 179 בגוש 6657 בשטח 1309 מ"ר חתמו על בקשת רישום הבית שהוקם על המקרקעין בפנקס הבתים המשותפים וכן על בקשה לרשום תקנון מוסכם ולאחר שהוכח לי שנתמלאו תנאי סעיף 142 לחוק ולאחר שנוכחתי לדעת כי אין מניעה בדין לרשום את התקנון המוסכם בהתאם לסעיפים 62 - 63 לחוק.

ובהמשך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מספר חלקת משנה	שטח רצפת הדירה	תאור הדירה	קומה	מס הדירה בתשריט	חלקים ברכוש המשותף	צמידות מיוחדות
179 / 1	149.00	דירה	ראשונה ושניה	1	1/2	אין
179 / 2	27.70	דירה	ראשונה	2	1/2	אין

73. ואלו החלקים הרלבנטיים מתוך התקנון המוסכם שנרשם לבית המשותף בתאריך 31.5.1984:

תקנון מוסכם

בהתאם לסעיפים 62 ו-63 לחוק המקרקעין תשכ"ט 1969

אני הח"מ קרן קיימת לישראל בעל מקרקעין הידועים כחלקה 179. בגוש 6657. בשטח 1309 מ"ר קובע בזאת כדלקמן:

1. בהתאם לאמור בסעיף 57 (ב) לחוק המקרקעין תשכ"ט - 1969 (להלן החוק) אני קובע כי שטחי הרצפה של הדירות כוללים מרפסות מקורות, אך אינם כוללים גזוסטראות (מרפסות שאינן מקורות) קירות חיצוניים ואינם כוללים קירות בין דירה לדירה אולם כוללים מחיצות פנימיות של הדירות.

2. א. החלקים ברכוש המשותף של הבית המשותף הצמודים לכל דירה ודירה יהיו שווים.

ב. שנויים ו/או תוספות בניה לדירה לא ישנו, למרות הרחבת שטח רצפתה של הדירה, את החלקים ברכוש המשותף של הבית המשותף הצמודים לאותה דירה.

74. ואלו הנתונים הרלבנטיים מתוך תשריט הבית המשותף כפי שהוא מופיע במרשם:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

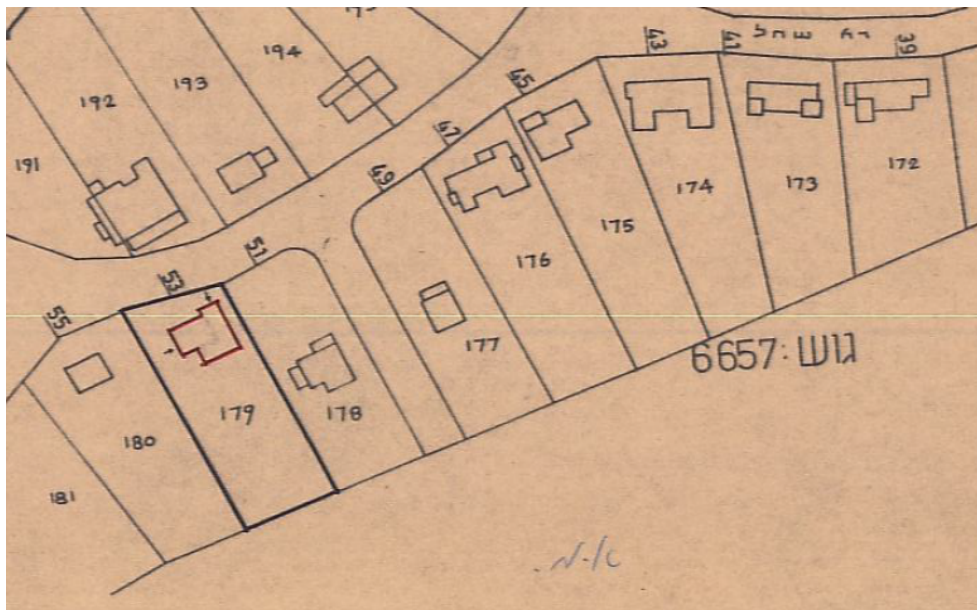
מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אביעזר שרותי הנדסאות בנין. יחוב התחיה 8 חולון. טלפון. 801678

מס' הגוש: 6657		מס' החלקה: 179		שטח החלקה: 1309 מ"ר	
מס' מבנים בחלקה	מספר הבניינה/קומות	מספר דירות	מספר שה"כ	המקום: הור השרון	השכונ: מגדיל
1	1	2	2	53	שחל
שם הרחוב מס' הבית					
מס' בניינה	מס' קומה	מס' דירה	מס' חלקה	מס' חלקים ברכוש משותף	שטח רצפת הדירה
	ראשונה	דירת קומב'	1	179/1	149.00
	ראשונה	דירה	2	179/2	27.70
				179/3	
				רכוש משותף	

ובהמשך:



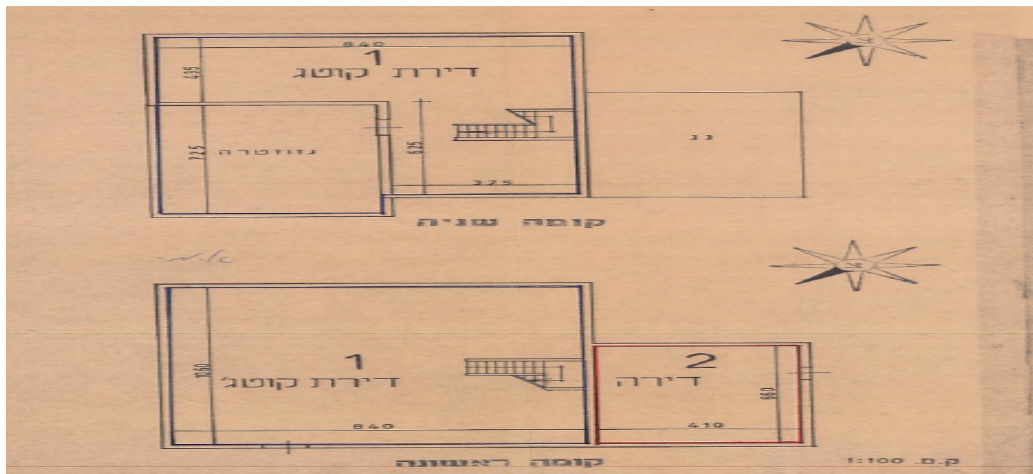


מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובהמשך:



75. כך שמסמכי המרשם מביאים למסקנה הברורה ולפיה שטח המגרש הוא 1,309 מ"ר, בין תתי החלקות אין גדר הפרדה, והוסכם כי החלקים ברכוש המשותף יהיו שווים, ללא קשר לגודל הדירה הקיים או כזה שיהיה בעתיד (סעיף 2 לתקנון המוסכם).

76. לפיכך, ובהינתן על חזקת הרישום כפי שהוסבר לעיל, על מי שטוען שיש לסטות ממסמכי הרישום, נטל כבד ביותר. במקרה שלפניי, מוטל הנטל על התובע אשר טוען כי יש לבצע חלוקה שונה המתעלמת מהמצב הרישומי של החלקה.

התובע לא עמד בנטל להוכיח שיש לחרוג מהמרשם ואף לא עמד בנטל להוכיח הסכמה מפורשת של בעלי הנכס הקודמים לחלוקה הנטענת בין תתי החלקות, ומשכך לא נוצר אף הסכם מכללא מכוחו ניתן לו רישיון במקרקעין

77. כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 569/21 כהן תקוה נ' בן עמי יובל (נבו 23.11.2023), מתן זכות לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, אינו עסקה במקרקעין הטעונה מסמך בכתב לפי סעיף 8 לחוק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המקרקעין, ולכן די בהסכמה בעל פה (ע"א 188/76 רזנוקס נ' הוטרר, פ"ד לא(1) 385, 382 (1976); ע"א (מחוזי מרכז) 27438-11-21 יצחק מינס נ' יצחק אהרון (נבו 08.05.2022)). עם זאת זכות שימוש ייחודי ברכוש המשותף שאינה כרוכה בהצמדה של אותו שטח לדירה, דורשת הסכמה ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות [ע"א 2525/92 ראוכברגר נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז(5) 850; רע"א 698/86 בן צור נ' נעים ששון (נבו 23.7.1987); יהושע ויסמן דיני קניין: בעלות ושיתוף 455-454 (1997)].

78. כך שבשונה מהסכמה למתן זכות קניינית, הטענה מסמך בכתב, הסכמה לעניין זכות לשימוש ייחודי, יכולה להינתן גם בעל פה, ואף להילמד מהנסיבות, אולם היא חייבת להיות מוכחת בראיות מספיקות [ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78, 83 (1982) (להלן: "פסק דין כליפא")].

79. עוד יש להוסיף כי ככלל אין די בקיומו של נוהג, היעדר התנגדות או הסכמה משתמעת כדי להעניק הרשאה לשימוש ייחודי ברכוש משותף [רע"א 259/99 חברת פליצה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 402 (2001); עש"א (מחוזי חי') 19110-02-16 אלון עדני נ' אורי ואקנין, בפסקאות 37-38 (נבו 23.05.2016)].

80. כך שאף אם ניתנה בעבר הסכמה לשימוש ייחודי ברכוש המשותף, לרבות הסכמה שבשתיקה, הרי שזו בבחינת רשות שימוש מכללא, אותה רשאים בעלי הדירות לבטל בכל עת על ידי גילוי דעתם כלפי מקבל הרשות כי אין הם מוכנים עוד להמשיכה [ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים, פ"ד לא(3) 210, 214 (1977); נ.ג. זלצמן, רישיון במקרקעין, הפרקליט מב, 24-25].

81. ככלל, רשות מכללא לשימוש במקרקעין היא זכות אישית (In personam) של בעל הרישיון כלפי נותן הרשות, וזאת להבדיל מזכות חפצית השרירה כלפי כולי עלמא (In rem). על כן, חליפו של הבעלים נותן הרשות, אשר רכש ממנו את הנכס מושא הרישיון, אינו כפוף לזכות שניתנה לבר-הרשות, והרשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תבוא לקיצה עם כל העברה של זכות הבעלות במקרקעין נשוא הרשות, שכן זכות זו פועלת במישור היחסים שבין בעל הרישיון ונותן הרשות בלבד [רע"א 4936/20 **עזבון המנוח מוחמד מחמוד סומרין ז"ל נ' הימנותא בע"מ**, בפסקה 17 (נבו 3.4.2023); ע"א 103/89 **אזולאי נ' אזולאי**, פ"ד מה(1) 477, 482-483 (1991); ע"א 6757/13 **נחום נ' רשות הפיתוח**, פסקה 19 (נבו 19.8.2015); (המפקח על המקרקעין עכו) 70/22 **יעקוביאן אילה נ' בכור טל**, בפסקה 37 (נבו 15.10.2023)].

82. עם זאת בהתקיים תנאים מסוימים, זכות כאמור יכולה לחייב גם אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן, אף שלא נרשמה (ר' פסק דין כליפא, ע"א 19/81 **ביבי נ' הורברט**, פ"ד לו (2) 497, 502; ע"א (מחוזי חיפה) 1020/03 **בובליל נ' שטיינר** (נבו 25.02.2004)).

83. רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, בהתחשב בעקרון תום הלב ובאינטרס ההסתמכות של מקבל הרשות שיצרה שינוי נסיבות משמעותי, תהא הרשות בלתי הדירה [ע"א 2307/99 **מכלוף רפאל נ' חג'ג' קלימו** (נבו 10.06.2001); רע"א 2427/14 **מרגוליס נ' דיין**, פסקה 4 (נבו 29.4.2014); ע"א 6757/13 **נחום נ' מדינת ישראל - רשות הפיתוח**, פסקה 17 (נבו 19.8.2015); ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 **קונצ'יצקי נ' שפלן**, פסקה 27 (נבו 3.4.2006) (להלן: "**עניין קונצ'יצקי**")]; ע"א (חי') 13721-05-16 **גבאי נ' הקש**, פסקה 30 (נבו 5.10.2016); ע"א (מחוזי י-ם) 25948-09-13 **מרדכי עזרן נ' דוד אביעד** (נבו 19.04.2015)].

84. לבסוף יצוין כי הפסיקה הכירה בהסכמות שניתנו בדיעבד כהגנה מפני תביעה לסילוק יד, ואף תוך כדי ההליך המשפטי [ע"א (מחוזי-חיפה) 31624-03-14 **רום נ' רוזנצווייג** (נבו 11.12.2014)].

85. **ובמיושם לעניינו** - אחיו של התובע, מר יוסף כרמי, שלטובתו רשומה הערת אזהרה בדירת התובע, העיד כי התובע רכש את הזכויות בחלקה מהבעלים הקודם, לרבות מיקום הגדר: (עמ' 4 ש' 21-34 לפרוטוקול דיון ההוכחות)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ש: מה הקשר שלך לעסקה?

יש הערת אזהרה לטובתי, כתוצאה מכספים שאחי לווה ממני לצורך הרכישה, וכתוצאה מכך יש הערת אזהרה ש: ספר לנו מה אתה יודע על המחלוקת בין הצדדים.

פתאום ביום בהיר אחד אדון אפרים או אשתו ליליאן או בנו יוסי, באו בדרישה לגבי מטרים שחסרים להם, ואחי אמר להם שכך רכש את המגרש וכך היה מאז ומעולם. ואחרי שהסתכלתי במסמכים, כך גם הוא רכש את השטח. עצם זה שעשרות שנים זה היה כך, זה קו הגבול. בעצם זה שהשכן רק אחרי 4 שנים פנה לאחי לגבי זה, מראה כמה זה נכון. כי הוא הרס את הגדר באוקטובר 2020, ואחי רכש באוגוסט 2016 את המגרש, כלומר חלפו יותר מ- 4 שנים.

86. כמו כן התובע עצמו העיד כי כך קנה את הנכס כאשר קו הגבול הוא היכן שעוברת הגדר (עמ' 5 ש' 44-46 לפרוטוקול דיון ההוכחות):
"אני קניתי בידיעה ובראייה ודרך מתווך ואחד שנשאר בעל הקרקע שקיבל את הירושה, חיים קרווני, שהוא היום כבר מבוגר, שזה קו הגבול איפה שעוברת הגדר, ושאלו מחלוקת עם השכנים, אלו הזכויות בבית."

87. מעבר לעדותו של התובע ולעדויות של אחיו, התובע לא הוכיח כי ניתנה הסכמה בעבר במסגרתה הסכימו כל בעלי הזכויות בבית המשותף כי חלוקת שטחי החצרות תהיה בחלוקה הנוכחית היכן שהגדר שהוסרה הייתה מותקנת. אף תצהירו של חיים קרוואני, שכאמור לא התייצב לחקירה נגדית (ומשכך המשקל שיש לייחס לתצהירו הוא נמוך ביותר), אינו מלמד מתי בדיוק ניתנה אותה הסכמה נטענת בדבר מיקום הגדר, ומי בדיוק הסכים לכך (סעיף 4 לתצהירו של חיים קרוואני). כמו כן אף אם הייתה הסכמה בעל פה בין הבעלים הקודמים לנתבעים - ולא הוכחה כי כך אכן היה - הסכמה שכזו לא עוברת אל התובע בהעברת הזכויות ועליו לקבל את הסכמת הנתבעים מחדש ככל שהנתבעים חזרו בהם מהסכמתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

88. כך שהתובע לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי חרף מסמכי רישום הבית המשותף, הייתה בין הצדדים הסכמה שונה בקשר עם חלוקת השטח. ומשכך טענת התובע נדחית.

המודד חוסאם מסארוה מונה כמודד בהסכמת הצדדים

89. מהמסמכים ועדויות הצדדים, עולה תמונה ברורה וחד משמעית לפיה הצדדים הסכימו באופן מפורש שהמודד יבצע מדידות לשם הכנת מפה טופוגרפית, שבין השאר תקבע חלוקה ברורה של הגבולות בין תתי החלקות.

90. כך למשל, הנתבעים צירפו התכתבות של התובע עם המודד, שבה הוא מודיע לנתבעים כי שלא ראה מקום לשנות את קווי הגבול וזאת לאחר שהתובע ביקש הבהרה (נספח 5 לכתב התביעה שכנגד).

91. התובע לא סתר את טענת הנתבעים ולפיה המודד הוזמן למדידה בשותפות עם התובע, שאף שילם למודד את חלקו בגין המדידה (עמ' 4 ש' 37 לפרוטוקול הדיון מתאריך 29.12.2021).

92. בדיון ההוכחות העיד המודד חוסאם מסארוה שהוזמן על ידי הנתבעים ונחקר על ידי ב"כ הנתבעים בחקירה ראשית ועל ידי ב"כ התובע בחקירה נגדית, ומצאתי כי עדותו מקובלת עלי.

93. בעדותו העיד המודד כי לפני שביצע את עבודות המדידה, שני הצדדים ליוו אותו ואת עבודתו (עמ' 2 ש' 18-20 לפרוטוקול דיון ההוכחות), כאשר הוא נשכר לשם הכנת מפה טופוגרפית (עמ' 2 ש' 37-38 לפרוטוקול דיון ההוכחות), וישנן כמה סיבות להכנת מפה טופוגרפית ובמילותיו "הסיבה הראשונה היא לצורך הסדרת בנייה לא חוקית או לצורך בנייה עתידית. בנוסף לבלי סוף סיבות, סיבות קנייניות וכו'.." (עמ' 3 ש' 10-11 לפרוטוקול דיון ההוכחות).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

94. למעשה, לאורך ההליך התובע לא התנגד לתכנית המדידה שצירפו הנתבעים ואף צירף אותה לתיק המוצגים שהגיש מטעמו. התובע אף לא הציג תכנית מדידה אחרת של מודד אחר, ומשכך מהראיות שלפניי עולה באופן ברור כי שני הצדדים הסכימו לכך שעל סמך המדידה של המודד חוסאם מסארוה, תוכן מפה טופוגרפית, שעל בסיסה גם ייקבעו גבולות ברורים בין הצדדים.

השטח שמחוץ לגבול חלקה 179 שהצדדים עושים בו שימוש ייחודי לא יכול לבוא בחשבון לצורך חלוקת השטח בין הצדדים

95. עיקר המחלוקת שבין הצדדים עניינו בשטח שמחוץ לגבולות החלקה. בעוד התובע סבור כי מכיוון ששני הצדדים מבצעים בו שימוש, יש לקחת אותו בחשבון לצורך קביעת החלוקה ביניהם, סבורים הנתבעים המתבססים על חוות דעתו של המודד, שאי אפשר לעשות זאת.

96. במסגרת המדידה שהצדדים הזמינו מהמודד חוסאם מסארוה בתאריך 29.4.2019 עולה כי ישנו שטח (מסומן במשולש כחול במפת המדידה) שהצדדים עושים בו שימוש ייחודי אך אינו שייך לשטח החלקה המקורית מספר 179.





מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

97. שטח זה כפי שעולה מחקירת המומחה הוא חלק מחלקת דרך ובפועל קיימת השתלטות על שטח זה ונעשה בו שימוש על ידי הצדדים. (עמ' 2 ש' 43-29 לפרוטוקול דיון ההוכחות)

"ש: מה זה המשולש בחזית, בין הגבול לבין רח' שחר?

ת: המשולש הזה עקרונית שייך לחלקת הדרך. כאשר חלקת הדרך לאורך כמה מגרשים נכנסת לתוך גדרות קיימים של מגרשים. אבל יתכן שהעירייה תיזום תכנית תב"ע שתשנה את הקווים, או שהיא יזמה או שזה תקוע באיזה מקום.

ש: זו הפקעה?

ת: זו לא הפקעה. זו חלקת הדרך כפי שהיתה במקור. לפעמים עושים פרצלציה על בסיס מצב קיים קובעים גבולות שגויים, וזה קיים בלי סוף, במיוחד במושבים. קובעים קווים עפ"י צילומי אוויר. וכשבאים לסמן פיזית בשטח, מגלים שמגוף המים וחצי מסככות השכן נמצאים אצל השכן השני.

ש: כשהזמינו לבצע העבודה מה ביקשו ממך להכין?

ת: ההזמנה הינה עבור מפה טופוגרפית. מפת השטח.

ש: יכול להיות שביקשו ממך לחלק את השטח לפי מצב קיים?

ת: לא זוכר, זה 3-4 שנים אחורה. ניתנה הצעת חלוקה או חלופות לחלוקה.

ש: האם נכון שהמשולש שדיברנו עליו קודם הוא בשימוש? האם זה נכון שהגדרות של בעלי הקרקע לא נמצאים על גבול המשולש אלא על גבול הרחוב?

ת: כן, ברור. רואים בתכנית את השערים, את האדניות, הפילר."

98. בעדותו העיד המודד כי מבחינתו הגורם החשוב ביותר הוא גבולות החלקה,

ובמילותיו "מה שקדוש מבחינתי כמודד זה המסגרת של גבולות החלקה" (עמ' 2 ש' 26 לפרוטוקול דיון ההוכחות), ומשכך הסביר המודד שלצורך הכנת המפה הטופוגרפית שבמסגרתה גם הציע היכן תעבור הגדר בין שתי תתי החלקות, היה חייב להתעלם משטח שמסומן כדרך והוא מחוץ לגבולות החלקה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

99. המודד הסביר כי אף על פי שנעשה בשטח זה שימוש על ידי הצדדים, מכיוון שהשטח ממוקם מחוץ לגבולות החלקה, הוא אינו בבעלות הצדדים, ולכן לא ניתן לחלק ביניהם שטח שאינו בבעלותם ולקחת אותו בחשבון לעניין המדידה. והסביר זאת המודד היטב בעדותו: **"אבל כסף לא שלו, זה שימוש בדבר שאינו שלו. יש שם ערימת כסף, אם ניקח אותו כל אחד יוכל לקנות מרצדס. אבל זה לא שטח שלהם, שהם יכולים להתחלק בו. כי זה שייך לדרך, לא לחלקה, מחוץ לגבולות החלקה המקורית"** (עמ' 3 ש' 1-3 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

100. גם הצדדים בחקירתם לא חלקו על כך שהשטח אינו שייך לחלקה המקורית והם עושים בו שימוש ייחודי בידיעה שבעתיד הרשות המקומית תחזיר לעצמה את השטח. כפי שהעידה הנתבעת 2 (עמ' 15 ש' 27-29 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

"ש: את עושה היום שימוש בשטח הדרך של העירייה. אם נצטרך להתכנס לגבולות בתשריט, גם אז תצטרכי להשיב שטח.

ת: לא נראה לי. אצטרך להשיב לעירייה, לא לכם."

101. התובע העיד שאף על פי שהשטח אינו שייך לחלקה המקורית, בקביעת קו הגבול יש להתחשב בכל השטח שנעשה בו שימוש כולל בשטח שאינו שייך לחלקה המקורית (עמ' 6 ש' 19-22, עמוד 7 ש' 8-9 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

102. מסקנתו של המודד ולפיה לא ניתן לחלק בין הצדדים שטח שאינו שייך להם, מקובלת עלי, והיא עומדת בקנה אחד דיני הקניין, אשר כידוע מושתתים על העיקרון הגדול ולפיו ככלל **"אין אדם יכול להקנות לזולת זכויות שאינן בידו"** (nemo dat quod non habet) [ע"א 3391/22 **בנק לאומי לישראל בע"מ** נ' **דוד קונפנינו**, בסעיף 60 (נבו 03.12.2023)]. משכך גם בענייננו הצדדים לא יכולים לחלק ביניהם שטח שאינו שייך להם, וככל שהיו מסכימים כי כך יתבצע – דבר שכאמור לא אירע בענייננו – ממילא הסכמה זו בדבר חלוקת השטח שאינו בבעלותם, היתה מבוטלת בהתאם להוראות סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 [ראו פסק דינו של כב' השופט שפסר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעניין ת"א (מחוזי מרכז) 62507-05-19 תקוה רובינסון נ' עיריית פתח תקווה, בפסקה 110 (נבו 01.01.2023).

103. בהינתן שאין מחלוקת על העובדה כי השטח שבחזית החלקה הגובל עם רחוב שחל, בצורת משולש אינו שייך לחלקה המקורית הרי שבקביעת קו הגבול שיעבור בין החלקות צודק המודד שאין מקום להתייחס לשטח שמחוץ לחלקה המקורית.

לצורך שאלת סילוק היד - החלוקה בין שתי תתי החלקות תיעשה באמצעות קו הגבול הצהוב במפת המדידה

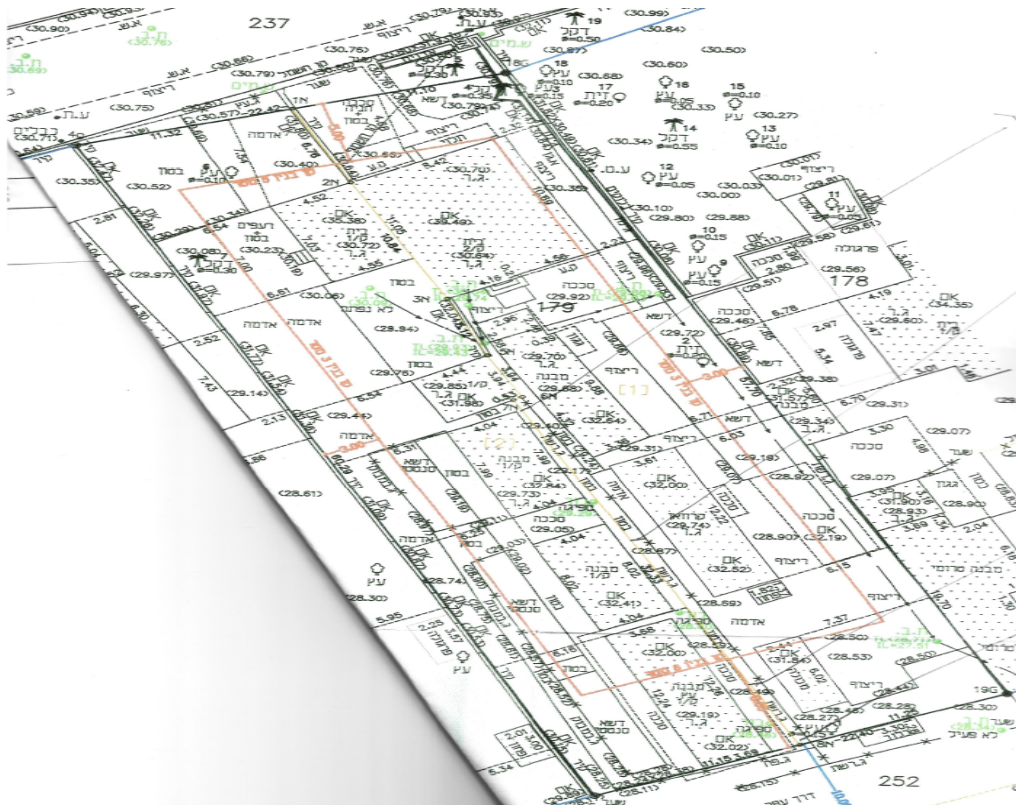
104. במפת המדידה, שערך המודד חוסאם מסארוה, חילק המודד את השטח בין הצדדים באופן שיוויוני כך שכל אחד מהם יהיה בשטח שווה של 645.5 מ"ר (הצד השמאלי במפה הוא השטח של התובע, ואילו הצד הימני במפה הוא שטח הנתבעים. בהתאם למפה המוצעת, חולקה החלקה, כאשר הקו הצהוב במפת המדידה, ממחיש היכן אמור לעבור קו הגבול בין הצדדים. להלן החלק הרלבנטי מתוך מפת המדידה מתאריך 29.4.2019.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



105. לאחר עיון בטענות הצדדים בראיותיהם ובעדויותיהם, לרבות במפת המדידה ובעדותו של המודד, החלטתי לקבל את טענת הנתבעים ולפיה קביעת גבול החלוקה בין שתי תתי החלקות, לצורכי שאלת סילוק היד, תיעשה באמצעות קו הגבול הצהוב במפת המדידה של המודד חוסאם מסארוה מתאריך 29.4.2019. למסקנה זו הגעתי מכמה סיבות.

106. ראשית, מפת המדידה ותכנית החלוקה שנערכה על ידי המודד בתאריך 29.4.2019 היא הראיה היחידה בתיק שעל פיה ניתן להכריע היכן יעבור קו הגבול בין שתי תתי החלקות. שנית, ראייה זו הוגשה על ידי שני הצדדים, הן על ידי התובע (הוגשה כנספח 3 בתיק מוצגי התובע. ועל ידי הנתבעים הוגשה כנספח ג' בתיק המוצגים מטעם הנתבעים). שלישית, קו הגבול הצהוב שבתוכנית המדידה מחלק את שטח החלקה 179 תוך התחשבות במבנים הקבועים ובמבנים הארעיים לשני חלקים **שווים** לפיכך הגעתי למסקנה כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לצורכי שאלת סילוק היד, קו הגבול הצהוב כפי שמצוין בתוכנית המדידה הוא קו הגבול בין שתי תתי החלקות.

107. ער אני כי המודד העיד כי הקו הצהוב שמסומן כקו גבול חוצה את החלקה לשני חלקים שווים ומדובר על קו מוצע ולא קו קדוש וקיימות עוד אפשרויות לחלוקה (עמ' 2 ש' 10-15 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

108. אלא שכאמור, התובע לא הציג מסמך אחר שבאמצעותו אפשר לקבוע את קו הגבול, וזאת חרף ההזדמנויות שניתנו לו. משכך יחול הכלל בדבר אי הבאת מסמך רלבנטי – הקובע שהימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית או עדות רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מובילה ככלל למסקנה כי אילו הובאה הייתה פועלת נגדו [ראו ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (נבו 20.3.2018) ע"א 3886/12 זאב שרון קבלנות בנין ועפר בע"מ נ' מנהל מע"מ, פסקה 34 (26.8.2014)].

109. לפיכך, משזו התוצאה שאליה הגעתי, הסעד שביקש התובע בתביעה הראשית, ולפיו על הנתבעים להקים את הגדר מחדש במיקומה הקודם, נדחה, שכן מיקומה הקודם אינו משקף את החלוקה השוויונית בין הצדדים, וכך קו הגבול בין הצדדים לצורכי שאלת סילוק היד, יהיה הקו הצהוב במפת המדידה מתאריך 29.4.2019.

סילוק יד

110. ראשית אתייחס לטענת התובע כי קיימת היעדר יריבות משפטית של התובעים שכנגד 1 ו - 3, לדרוש סילוק יד במקרקעין, מאחר שאינם בעלי זכויות. אלא שדין טענה זו להידחות, ואסביר. בתביעה לסילוק יד אין צורך לצרף כתובעים את כלל הבעלים או השותפים. אכן, כל אחד מהשותפים זכאי להגיש תביעה בכל הנוגע לפלישה למקרקעין בו הוא בעל זכויות, ואינו חייב להגיש את התביעה בשם כל השותפים [סעיף 31(א)(3) לחוק המקרקעין; רע"א 1475/94 פייר בושאר נ' רות פרידלנדר (נבו 13.9.1994)]. במיושם לענייננו- אין מחלוקת כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת 2 היא בעלת הזכויות בדירה. עוד אין מחלוקת כי הנתבע 1, שאומנם אינו רשום כבעל זכויות, אך הוא נשוי לנתבעת 2, ומתגורר בדירה, ומשכך הוא נחשב כ"מחזיק" בדירה. כמו כן, התובע עצמו צירף את הנתבעים 1 ו-3 לתביעה בהליך הראשי. לגבי הנתבע 3 אם יימחק מכתב התביעה שכנגד הדבר לא יגרום למחיקת ההליך, או למחיקת הסעד לסילוק יד, שכן עדיין תישאר בהליך למצער הנתבעת 2 כתובעת שכנגד. משכך אני דוחה את טענת היעדר היריבות שהעלה התובע.

111. מכיוון שהחלטתי לקבל את טענת הנתבעים ולפיה קו הגבול הוא הקו הצהוב כפי שבא לידי ביטוי במפת המדידה שערך המודד. אדון בסעד שהתבקש על ידם לסילוק יד.

112. פסק הדין המנחה בנושא סילוק יד, הוא פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה(1) 199 (1999) (להלן - "פסק דין רוקר"), שבמסגרתו נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים יש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים (ראו גם (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 649/21 נציגות הבית המשותף ברחוב בילו 15 פתח תקווה נ' רז יוסף משה, פסקה 51 (נבו 26.10.2022); (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 783/20 מקחניאן מרדכי נ' אדיר אורי, בפסקה 64 (נבו 11.04.2022)).

113. במסגרת פסק דין רוקר נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי הדין (ההדגשות אינן במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

114. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242).

115. אשר לשיקול הראשון עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה – אין מחלוקת ששטח הכולל של החלקה הוא 1309 מ"ר. כשנשאל אחיו של התובע מה עמד לנגד עיניו כשרכש את החלקה, השיב כך "אחי קנה בית יחד עם שטח שצמוד אליו, סה"כ גודל החלקה 654.5 מ"ר מתוך 1309 מ"ר שיש לשני הצדדים" (עמ' 4 ש' 19-20 לפרוטוקול דיון ההוכחות).

116. אלא שלו הייתה מתקבלת טענת התובע ולפיה יש למקם את הגדר במיקומה הקודם, שטח הנתבעים לא היה 654.5 מ"ר (כפי שצריך להיות על פי תכנית המדידה והסכמי המכר), אלא שטח קטן יותר שכן בהינתן כי הקו הצהוב הוא קו הגבול אשר מחלק באופן שיוויוני את שטח החלקה בין הצדדים, הרי ששטח הפלישה של התובע לתוך שטח הנתבעים הוא כ-23 מ"ר שטח פלישה. כלומר קיימת פלישה ניכרת אל שטח הנתבעים. מכיוון שמדובר בפגיעה קניינית, עוצמת הפגיעה גבוהה.

117. אשר לשיקול השני - עוצמת הפגיעה בזכות – בקביעת קו הגבול החדש נוצרת לנתבעים פגיעה קניינית בשטח של כ- 23 מטרים רבועים, ובעניינו מדובר בתפיסת השטח לצמיתות, ולא בתפיסה ארעית, ומשכך גם שיקול זה פועל לחובת התובע.

118. אשר לשיקול השלישי שעניינו עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות (שהוא כאמור שיקול משני בחשיבותו לשני הראשונים) – התובע נשאל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על ידי בדיון ההוכחות מהו הנזק שייגרם לו אם קו הגבול יהיה הקו הצהוב, וכך קיבלו הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון:

"נניח שהקו הצהוב הוא קו חלוקת הגבול. הוא קו מוצע. מה הנזק? מה ההפרעה שתיגרם לך? אתה צריך להרוס משהו?

אצטרך להרוס את בורות הספיגה. כמה שפחות הוצאות לאחד הצדדים. צריך יהיה להזיז כמה דברים קרובים. כשהקמנו יחידות הגדר היתה קיימת. עכשיו יהיה צריך להזיז כל המבנים והדברים כדי שיוכלו לעבור. זה הוצאה כבדה, זה כמה אלפים. צריך להביא מנוף ולהזיז 3 יחידות, ולהזיז את הביוב לפי כללי העירייה. להזיז את יחידות הדיור, הקרוואנים, צינורות המים. צינורות המים יושבים על הבטון. כשחוסאם ביצע המדידה הכל היה קיים. הוא ביצע בשטח, לא לפי תצלומי אוויר.

ש: הקו המוצע בשטח הושם במקום שהיה נראה לו שלא יהיה שום נזק. ת: כמו שהוא כתב שהשער לא פעיל, מאחור, והשער פעיל, ואפשר לבוא ולראות. יש צילומים שהשער עובד. הקו הצהוב שאנו מדברים עליו הוא נתן פחות או יותר, אך לא התחשב, יש שם הצינורות. הצילומים קיימים. בעדותם הם טענו שהרסתי את הגדר והצבתי קרוואנים ופלשתי לשטחם. ופה הוכחתי שהיתה גדר, ובא המודד והעביר את הקו."

כאמור, שיקול זה הוא משני בחשיבותו לשני השיקולים הראשונים, אך לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, החלטתי שעוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות, אינה פועלת לטובת התובע בנסיבות אלו. התובע לא תמך את טענותיו במענה לשאלותיי בהערכת שמאי או בהצעות מחיר לביצוע העבודות אך נתן הערכה גסה כי העבודות יעלו לו אלפים בודדים.

119. אשר לשיקול הרביעי - התנהגותם של הצדדים - בהתאם לגישה בפסיקה פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. בענייננו, הקו גבול החדש שמסומן בצבע צהוב משווה בין גדלי השטחים של הצדדים כך שלכל צד יהיו 654.5 מטרים רבועים כך שכ - 23 מטרים רבועים יוחזרו לשטחם של הנתבעים. אני סבור כי תפיסה לצמיתות של שטח זה, פועלת לחובת התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

120. לפיכך, בשוקלי את השיקולים שהותוו בפסיקה, ובהינתן שקבעתי שקו הגבול החדש הוא הקו הצהוב שבתוכנית המדידה מתאריך 29.4.2019, אני מקבל את התביעה של התובעים שכנגד סילוק יד. ומשכך על התובע לסלק ידו משטח הנתבעים בהתאם לתוכנית המדידה מתאריך 29.4.2019.

121. עם זאת, קיבלתי את טענותיו של התובע ביחס לבורות הספיגה, וכך התובע לא יצטרך להזיז את בורות הספיגה, לרבות צינורות מים וחשמל ככל שהם מוטמנים באדמה, שכן כפי שכתבתי בעבר בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 493/19 **חמרי עזרא נ' קטיעי קונסלסיון רונית** (נבו 02.09.2021) כפי שההרמוניה הייחודית ומרקם החיים בבית המשותף, מחייבים כי בעל דירה יאפשר לבעל דירה אחר, לתקן את דירתו, גם אם התיקון צריך להיעשות מתוך דירתו, כך גם בעל דירה צריך לאפשר לבעל דירה אחרת, להעביר צינור ביוב, קו חשמל, צינור לדוד השמש וכו'. הנחת צינור ביוב בקרקע פרטית, הגם שיש בה כדי לשמש צדדים נוספים מלבד בעלי הקרקע הפרטית, אינה דבר נדיר ומדובר בפרקטיקה נהוגה (השוו בש"א (שלום עכו) 3164/99 **מחמד סאלח סואעד ואח' נ' מועצה אזורית משגב**, תשנ"ט (3) 496 (1999) בפסקה 14). דוגמאות נוספות אפשר למצוא גם בסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962; בסעיף 46 לחוק משק החשמל תשנ"ו-1996; בסעיף 49 לחוק משק הגז הטבעי, תשס"ב-2002; בסעיף 42 לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001 וכו'. בעניינו הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שמדובר בבית משותף, כאשר הזכות הקניינית של כל בעל דירה כפופה כאמור גם לזכויותיהם של בעלי דירות אחרים. ומשכך סילוק היד לא יחול על בורות הספיגה של התובע, ואלו יוכלו להישאר במקומם הנוכחי.

טענת הנתבעים לדמי שימוש ראויים - נדחית

122. אשר לדמי השימוש הראויים. בהתאם לפסיקה, [ראו למשל ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 3/98 **חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני** (נבו 28.2.1999)] למפקח על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רישום מקרקעין סמכות לדון גם בדמי שימוש ראויים כאשר הוא דן בתביעה שעילתה סילוק יד (ראו הרחבה בעניין זה בפסק הדין **בעניין חבאני**, בפסקאות 33-36).

123. אלא שהנתבעים לא צירפו הערכת שמאי לדמי השימוש הראויים. כידוע, על התובע להוכיח לא רק את העובדה שנגרם לו נזק אלא להוכיח גם במידת ודאות סבירה את גובה הנזק [רע"א 4933/22 שלמה ביטון נ' בונייד בנייה פתוח והשקעות בע"מ, בפסקה 18 (נבו 24.04.2023); ע"א 7905/98 Aerocon C.C. נ' הוק תעופה בע"מ, נה(4) 387 (2001), בפסקה 18].

124. כמו כן, הנתבעים זנחו את טענת דמי השימוש בסיכומיהם, ומשכך יש להחיל את הכלל ולפיו טענה שנטענה בכתב טענות אך לא הועלתה בסיכומים דינה כדין טענה שנזנחה [ע"א 1134/11 ר.מ שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר שבע, פסקה 29 (12.5.2013); ע"א 2950/07 סולימאן נ' מדינת ישראל - מנהל מקרקעי ישראל, פסקה 32 (26.10.2009)].

125. לסיכום - טענת הנתבעים לדמי שימוש ראויים - נדחית.

סיכום אופרטיבי

התביעה הראשית

126. התביעה הראשית נדחית על כל סעיפיה. הן ביחס להתקנת גדר הפרדה בין תתי החלקות במיקומה הקודם, והן בקשר לצו העשה בעניין הסרת חלונות ותריסים שהותקנו שלא כדין, תוך ששמורה לתובע האפשרות לפנות בהליכים המתאימים, בלי שיהיה בכך כדי להביע דעה או עמדה בקשר לסיכוייהם.

התביעה שכנגד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

127. התביעה שכנגד מתקבלת באופן חלקי, ובאופן הבא:
128. ניתן צו עשה המורה לתובע לסלק את ידו מעבר לקו הצהוב של מפת המדידה של המודד חוסאם מסארוה מתאריך 29.4.2019 באופן שתוחזר החזקה בשטח הסגת הגבול לנתבעים, כששטח זה פנוי מכל אדם וחפץ על פי ההוראות שלהלן:
129. המפה הטופוגרפית שנערכה בתאריך 29.4.2019 על ידי המודד המוסמך חוסאם מסארוה וצורפה לתיק מוצגי התובע כמוצג 3 – תהיה חלק בלתי נפרד מפסק הדין (להלן - "מפת המדידה"). קו הגבול לצורך סילוק היד יהיה הקו הצהוב המופיע במפת המדידה (כפי שהוא מומחש בסעיף 104 לפסק הדין).
130. סילוק ידו של התובע ייעשה בתוך 90 ימים מיום פסק הדין. העבודה תבוצע על ידי איש מקצוע מיומן שתחום מומחיותו בביצוע עבודות מסוג זה. התובע יישא בהוצאות הכרוכות בסילוק היד כאמור.
131. סילוק היד לא יחול על בורות הספיגה וכן בקשר לצינורות מים, הביוב ומערכות חשמל המשמשים את התובע ככל שאלו מוטמנים באדמה, גם אם הם ממוקמים בתוך השטח של הנתבעים בהתאם לקו הצהוב במפת המדידה ותינתן לתובע או למי מטעמו גישה אליהם, לשם ביצוע תיקונים על חשבונו ובאחריותו ככל שיידרש בקשר לכך, זאת לאחר תיאום מראש עם הנתבעים או מי מטעמם לרבות הנכנס בנעליהם.
132. ככל שמדובר בצנרת או בכבלי חשמל, שאינם מוטמנים באדמה – על התובע לדאוג להעתיקם לשטחו ומעבר לקו הצהוב במפת המדידה לכל המאוחר בתוך 90 יום ממועד פסק הדין. גם פעולות אלו יתבצעו על ידי איש מקצוע מיומן שתחום מומחיותו בביצוע עבודות אלו. כל ההוצאות בגין סעיף זה יחולו על התובע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

133. ככל שמי מהצדדים יהיו מעוניין לבנות גדר חדשה (להלן - "הגדר העתידית"), זו תיבנה בהתאם למיקומה לפי מפת המדידה, בקו הצהוב, בפיקוח הנדסי ובכפוף להיתר בנייה – ככל שנדרש היתר, והכול בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ותקנותיו. העבודות יבוצעו על ידי איש מקצוע שזו מומחיותו. ככל שבין הצדדים תהיה מחלוקת בקשר למיקומה המדויק של הגדר העתידית, יפנו הצדדים למודד חוסאם מסארוה, כדי שיסמן בשטח עצמו, את מיקומה המדויק של הגדר העתידית. סימון בשטח שיתבצע על ידי המודד חוסאם מסארוה, יהיה סופי ומכריע. ההוצאות בגין סעיף זה יחולו שווה בשווה על הצדדים.

134. הסעד בדבר דמי שימוש ראויים - נדחה.

135. מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין אני מורה לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על תתי החלקות 1 ו- 2 בחלקה 179 בגוש 6657. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.

הוצאות ההליך

136. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך. הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך ([ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/351/2021, 6/513/2021

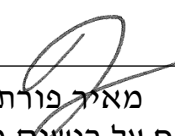
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

137. תקנה 151 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת את תכלית חיוב בעל דין בהוצאות ההליך. תקנה 152 לתקנות קובעת שברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין. ואילו תקנה 155 לתקנות קובעת כיצד יחושב סכום ההוצאות.

138. לאור האמור, לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל, ולאחר ששקלתי את מלוא טענות הצדדים ואת התנהלותם בהליך, לרבות כך שהתביעה הראשית נדחתה במלואה, ואילו התביעה שכנגד התקבלה באופן חלקי ובשים לב לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימאלי המומלץ), תש"ס-2000, החלטתי להורות על חיוב התובע, לטובת הנתבעים בהוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 7,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי התובע, לנתבעים בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישא ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים.

ניתן היום, ט' ניסן תשפ"ד, 17 אפריל 2024, בהעדר הצדדים.


מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה